

1500279-92.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... o crime em comento, já que tais condutas (uso e tráfico) frequentemente coexistem. A esse respeito, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500279-92.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164478/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25608472 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2164478 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIOSVALDO JOSE DE DEUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

ARIOSVALDO JOSÉ DE DEUS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 144), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 151/153).

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls. 156/157) e o acusado foi citado (fls. 186).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 189/190).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 202/205).

A defesa sustentou nulidade na atuação policial e requereu a absolvição do réu.

Subsidiariamente, postulou a fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação de benesses legais (fls. 216/227).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 14), fotografias (fls. 21/23), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/121) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos e aduziu, em síntese, que está sendo falsamente incriminado por possuir antecedentes criminais. Afirmou que estava bebendo em um bar e, enquanto usava o banheiro, o policial militar invadiu o cômodo, perguntou-lhe se tinha antecedentes e, diante de sua resposta afirmativa, comunicou que seria preso novamente. Não viu entorpecente no bar. A viatura fez uma parada na base da polícia militar no caminho para a delegacia, então acredita que a droga tenha sido pega ali para ser apresentada na delegacia. Trabalhava como pintor e auferia aproximadamente R\$ 4.000,00.

O policial militar Aguinaldo relatou, em suma, que estava em patrulhamento quando avistou o acusado caminhando e observou que ele tinha um objeto grande na cintura, ocultado sob as vestes, pelo que resolveu abordá-lo. Ao notar a manobra de retorno da viatura e a iminente abordagem, o acusado alterou sua trajetória e andou apressadamente até um bar. Ele ingressou no banheiro do estabelecimento situado próximo à saída e tentou trancar a porta, mas ela não tinha chave. Entrou no cômodo e viu o momento em que ele pegou o objeto que tinha na cintura, enrolado em uma sacola preta, e o dispensou atrás do vaso sanitário. O objeto se tratava de um tijolo de maconha. Havia dinheiro na posse do acusado. O réu foi anteriormente preso por tráfico e o abordara dias antes dos fatos em análise, contudo nada de ilícito foi encontrado com ele.

No mesmo sentido, em linhas gerais, as declarações do policial militar Leandro.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra ilegalidade na ação policial, como sustentado pela defesa. A dinâmica relatada pelos policiais era suficiente para justificar a fundada suspeita motivadora da abordagem, tanto que houve o encontro das drogas com o réu, o que afasta a alegação defensiva de nulidade. Sobre o tema, vale citar trecho de decisão proferida pela E. 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“E se não lhes permitirmos que abordem quem lhes parecer suspeito por adoção de atitudes que lhes são reveladoras de suspeição em razão da rica experiência adquirida (pressuposições empiricamente justificadas), fatalmente vamos lhes castrar a efetividade no enfrentamento à criminalidade, que grassa cada vez mais desinibida. (...). Logo, é indevido esperar que o policial seja ingênuo na identificação de certa conduta, por ele já visualizada em outras situações de tráfico, como denotadora de suspeição, pelo contrário, é louvável que tenha ganho, com a experiência, aludida expertise, a mesma que se verifica, por exemplo, quanto aos agentes policiais e alfandegários nos aeroportos quando elegem pessoas à revista por meio de leitura corporal que passa desapercibida por gente comum” (Ap. Crim. 1500559- 92.2021.826.0535, julgada em 08.08.2022).

Veja-se, ainda, excerto de acórdão proferido pela E. 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Com efeito, a palavra dos policiais, assim como vale para dar atestado do que presenciaram e do que apreenderam com o acusado, vale para justificar a abordagem e a fundada suspeita, cuja prova decorre menos do quanto disseram e mais do que efetivamente encontraram. Ou seja, não há maior atestado de que a suspeita era fundada do que o encontro da droga com o sujeito alvo da busca pessoal e a consequente prisão em flagrante. (Apelação Criminal nº 1500428-11.2022.8.26.0559, julgada em 12/09/2002).

No mérito, as provas são suficientes para segura comprovação do crime narrado na denúncia.

A negativa do réu se encontra isolada nos autos e foi rechaçada pelas declarações das testemunhas.

Cumpra desde logo observar que o réu não apontou motivo crível que justificasse a falsa incriminação por parte dos policiais, a quem declarou sequer conhecer.

De outro lado, as narrativas dos policiais se mostraram coerentes e harmônicas entre si e com as demais provas.

A destinação para entrega a terceiros restou demonstrada pela expressiva quantidade de maconha apreendida e pela ausência de comprovação de que o réu auferisse renda lícita.

E ainda que o réu também seja usuário, tal fato não afastaria o crime em comento, já que tais condutas (uso e tráfico) frequentemente coexistem. A esse respeito, veja-se:

“TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Assim, não há como acolher as teses defensivas, pois restou suficientemente comprovada a prática, pelo acusado, do crime narrado da denúncia.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a elevada quantidade de entorpecente apreendida, apesar do seu menor potencial lesivo, se comparado a outras drogas. Ainda, vislumbro da certidão de fls. 174/176 que o acusado ostenta maus antecedentes (Processos nº 0005824-87.2012.8.26.0302 e 0006753-28.2009.8.26.0302) e que uma das condenações é decorrente da perpetração de tráfico de entorpecentes. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inaplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, ante os maus antecedentes do acusado.

Tendo em vista a pena aplicada, os motivos esposados na primeira fase e os maus antecedentes do réu, a reprimenda deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei

das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o acusado ARIOSVALDO JOSÉ DE DEUS, qualificado nos autos, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram a sua custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do acusado. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA